

1500824-83.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme passo a expor. Isso porque é certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500824-83.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2161783/2021 - DEL.POL.QUADRA, 18512129 - DEL.POL.QUADRA, 25/21/504 - DEL.POL.QUADRA, 2161783 - DEL.POL.QUADRA

Réu:

GEOVAN MARTINS DOS SANTOS e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" e Art. 35 "caput" ambos do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

05/07/2022

Em 05 de julho de 2022, às 14h30, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. Drª MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MMª Juíza de Direito Titular, comigo Assistente Judiciário ao final nomeado, pela MMª Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do Dr. Carlos Eduardo Pozzi, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, os réus GEOVAN MARTINS DOS SANTOS e ENIO BASTOS DA SILVA, bem como as suas respectivas Defensoras, Drª Camila Pilla Barroso, OABSP nº 419985; e Drª Juliana Pomaroli de Oliveira, OABSP nº 162460. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual, as testemunhas arroladas em comum pelo Ministério Público e pela Defesa do réu GEOVAN, Reinaldo Pinto da Fonseca e Jorge Fernando Soares, ambos Policiais Militares. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de os acusados se entrevistarem reservadamente com suas Defensoras. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório dos réus. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams,

conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MMª Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. Os réus ENIO BASTOS DA SILVA e GEOVAN MARTINS DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, eis que: 1) no dia 15 de junho de 2021, na cidade de Quadra, Comarca de Tatuí, se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas; e 2) no dia 15 de junho de 2021, por volta das 11h30, nas dependências do "Posto Chicago", localizado na Rodovia SP 280, Km 149, na cidade e Quadra, Comarca de Tatuí, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de designios, identidade de propósitos, traziam consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 6 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 11,2 gramas, e 18 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 25,4 gramas,, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, os acusados se dedicavam ao tráfico ilícito e, para tanto, traziam consigo as porções de "maconha" acima mencionadas e permaneciam juntos no local da abordagem, qual seja, o estacionamento do "Posto Chicago", às margens da Rodovia SP 280, que elegeram como "ponto", entregando drogas para passageiros de ônibus que conduziam detentos em ocasião de saída temporária ("saidinhas). Policiais Militares estavam em serviço quando receberam informação anônima dando conta de que os denunciados estavam no estacionamento do "Posto Chicago", entregando drogas para detentos beneficiados com "saída temporária", que estavam a bordo de ônibus fretados estacionados temporariamente no local. Na delação, constava que os ônibus chegavam, permaneciam ali parados por algum tempo e, mesmo depois que seguiam viagem, ENIO e GEOVAN permaneciam no local, aguardando usuários para promover a venda oportuna de entorpecentes, a todo tempo transitando entre os ônibus que chegavam e a parte dos fundos do restaurante. De imediato, na posse da descrição das vestimentas dos acusados, os Policiais se dirigiram para o local indicado e, lá chegando, avistaram ENIO e GEOVAN nas dependências do posto de serviços e deliberaram pela abordagem. Ao perceber a aproximação da viatura, ENIO dispensou as drogas que trazia consigo no chão. GEOVAN, por sua vez, permaneceu parado e foi abordado. Assim é que, em revista pessoal, os policiais encontraram 18 porções de "maconha" no bolso da blusa de GEOVAN, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R\$390,00 em espécie, dinheiro angariado com a venda de drogas que ele promovia no local associado com ENIO. Verificando o que ENIO havia dispensado, os policiais encontraram outras 6 porções de "maconha", dispostas em embalagens individuais, de modo a facilitar a mercancia ilícita, drogas que lhe pertenciam e estavam destinadas à venda. Ato contínuo, os denunciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia e autuados em flagrante. No relatório de análise de conteúdo de telefone celular apreendido em poder de ENIO, a fls. 140/149, constam diálogos claramente alusivos ao tráfico ilícito de drogas. Os réus foram notificados (fls. 188) e apresentaram Defesa Preliminar (fls. 183/184 e 196/197). Assim, por decisão proferida no dia 29 de junho 2022, foi recebida a denúncia (fls. 198/200). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, ultimando-se com os interrogatórios dos réus, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela absolvição dos réus, sustentando insuficiência probatório, bem como, subsidiariamente, a desclassificação delitiva e, finalmente, em caso de condenação, pela incidência de todas os benefícios legais cabíveis a

incidir em dosimetria da pena e na fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 33/34 e 37/38, bem como Certidões a fls. 35/36 e 39. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido ministerial comporta parcial procedência, absolvendo-se os réus da imputação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme passo a expor. Isso porque é certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência delitiva: "Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:" (grifos aditados) No entanto, para se que não se confunda o mero concurso de pessoas – de que trata o art. 29 do Código Penal – com o delito de associação, estabeleceu-se o entendimento jurisprudencial e doutrinário que, para a caracterização do crime em comento, é imperioso que o dolo dos agentes que agiram em conluio projete-se por mais de um fato criminoso, ou seja, que pretendam exercer a narcotraficância em caráter permanente, estável e duradouro, denotando vínculo associativo e não mero concurso eventual. Neste sentido, coleciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. (...)” (STJ - HC: 214660 SP 2011/0178723-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013). Além disto, coleciono também o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "(...) Associação para o tráfico - Absolvição - Admissibilidade - O artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, não pode ser considerado um mero concurso de agentes, sendo necessário, para sua caracterização, a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de associar-se seja distinta da vontade da prática do crime visado (...)” (TJ-SP - APL: 00128516320108260344 SP 0012851-63.2010.8.26.0344, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/04/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014). Em idêntica lógica, assevera Guilherme de Souza Nucci que: "(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico (...)” (Nucci, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 1, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed, p. 337, item 103). Assim, observando a premissa estabelecida e examinando o conjunto probatório amealhado nos autos, noto que, embora haja comprovação de que os acusados exerciam o tráfico de entorpecentes, inexistem provas suficientes de que praticavam ou pretendiam perpetrar a narcotraficância em caráter permanente e de forma associativa. Verifica-se na transcrição de mensagens do celular do réu Enio (fls. 1401/160), que estavam envolvidos com a traficância, mas não associados entre si. Portanto, diante da ausência de provas em relação ao animus associativo entre os réus, imperiosa a absolvição deles no que se refere à imputação de ofensa ao art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. No mais, a pretensão acusatória merece ser acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10), pelo auto de constatação preliminar (fls. 11), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 102/106) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu ENIO, em solo policial (fls. 05), confessou que conhece GEOVAN do bairro onde moram e que se encontraram na data dos fatos, oportunidade em que ambos se dirigiram ao Auto Posto Chicago afim de vender entorpecentes. Esses entorpecentes foram adquiridos em Tatui há duas semanas atrás. Estava na posse de 15 porções. Por volta das 11:00, foram abordados pelos policiais

militares. Admitiu que, ao ver a aproximação dos policiais, tentou dispensar o entorpecente que trazia consigo, jogando-o ao solo. Os policiais localizaram o entorpecente que foi dispensado, informando, também, que, com GEOVAN, também foram encontradas algumas porções de maconha. Estava na posse de aproximadamente R\$ 300,00 (trezentos reais). Em juízo, disse que não estava traficando. Como é usuário estava com seis porções de maconha. Não chegou junto com Geovan, mas ele lhe deu a droga para usar. Nega que tenha feito a confissão na delegacia. Trabalha com pintura. Tem uma filha. Nunca foi processado. Da mesma forma, o réu GEOVAN, em solo policial (fls. 06), afirmou que conheceu ENIO na data e no local dos fatos. Estava no Auto Posto Chicago desde as 09:30h para esperar um primo seu. Estava na posse de 14 (quatorze) porções de maconha que se destinava ao tráfico. O entorpecente foi adquirido por ele de um conhecido para o seu uso, mas, como estava sem dinheiro, resolveu vender um pouco desse entorpecente para pagar as contas de casa. Por volta das 11:00, foram abordados pelos policiais militares. Os policiais localizaram com ele o entorpecente e a quantia de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais) oriundos do seu trabalho e de um pequeno empréstimo que fez de sua esposa. Em juízo, o réu disse que foi ao local para buscar a droga. Estava com quinhentos reais, queria comprar 25 gramas de maconha. Como o rapaz não tinha em pedaço, vendeu em porções fracionados. Comprou de um rapaz que estava de moto. Enio não estava ao seu lado, só depois que ele se aproximou. Não o conhece. Nega que estivesse vendendo ou entregando algo para indivíduos de camiseta branca. Permaneceu no local por 10 minutos. Trabalhava com pintura e bicos de vidraçaria. Não tem filhos. Antes desse processo, não tinha nenhum outro. Perguntas da acusação - nega que tenha feito qualquer confissão na delegacia, foi pressionado. Foi preso depois desses fatos por outro suposto tráfico, pois os policiais estavam de marcação com ele. Estava com 11 porções de maconha para seu uso e como estava com esse processo, o levaram preso. Isso ocorreu em Porangaba. Quanto aos policiais desses fatos, não os conhecia. Analisando a autodefesa dos acusados - colhida com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - observo que ambos negaram a prática dos fatos, bem como negaram terem feito qualquer confissão em solo policial. Ocorre que a versão dos réus nesta data é inconsistente e as versões colidem entre si. O réu Geovan afirmou nesta data que nem mesmo conhecia o corréu Enio, que apenas o viu no local. Já Enio disse ter sido convidado por Geovan para ir ao local fumar maconha e que ali Geovan lhe forneceu seis porções de maconha. Note-se que ambos os réus confessaram os fatos em delegacia e aqui negaram a prática delitiva. A frágil versão dos réus nesta data, apenas corrobora a autoria delitiva demonstrada pelos elementos probatórios que seguem. De fato, o Policial Militar Reinaldo Pinto da Fonseca, em sede policial (fls. 02/03), relatou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, receberam uma denúncia anônima de que havia ônibus fretados que transportavam presos de saidinha estacionados no pátio do posto Chicago na Rodovia Castelo Branco. O denunciante informou que havia duas pessoas estranhas no pátio, que ambos transitavam a todo momento até o final do restaurante, indo em direção as pessoas que estavam no interior destes ônibus. O fato levantou suspeita, haja vista que a medida que os ônibus iam saindo, ambos os acusados continuavam naquele local. Ademais, informou o denunciante que ambos os réus estavam com algo em mãos e passavam aos passageiros dos ônibus. Após o denunciante passar as características das vestimentas dos indivíduos, foi efetuado deslocamento até o local e, chegando, já foram visualizados ambos os réus em atitude suspeita no interior do posto. No momento em que os indivíduos avistaram a viatura, ENIO dispensou seis trouxinhas de entorpecente maconha que estava em suas mãos. Já GEOVAN, ficou parado e, em revista pessoal, foram localizadas 18 trouxinhas de entorpecente maconha no bolso de sua blusa. Indagados, os indivíduos disseram que estavam trabalhando e que estavam aguardando um familiar que passaria pelo local. Em juízo, o policial disse que receberam denuncia de tráfico de entorpecentes e foram ao local. Com base nas informações repassadas localizaram dois indivíduos que correspondiam as características. Abordados os réus foi encontrada droga com o réu Geovan. Indagado acerca de terem presenciado o ato de mercancia, a testemunha respondeu que sim, pois ao lado de Geovan havia vários rapazes, que estavam de camiseta branca e que

saíram com a presença da viatura. Não foi encontrada droga com Enio. A pessoa que fez a denúncia disse que vários indivíduos se aproximavam de um dos réus, e depois disso um parecia passar algo para o outro. Confirma que o denunciante relatou que os ônibus com detentos chegavam, os indivíduos saíam do local mas os réus ali permaneciam. Convergindo em mesmo sentido, o também Policial Militar Jorge Fernando Soares, em sede policial (fls. 04), corroborou integralmente a versão de seu colega de trabalho. Em juízo, disse que houve uma denúncia anônima sobre dois indivíduos no pátio do restaurante Chicago e que estavam vendendo droga. Era dia de "saidinha" e havia vários ônibus que deixavam detentos no local. Esses ônibus param no restaurante para os sentenciados fazerem refeição. O denunciante também repassou as características físicas dos indivíduos. Visualizaram os réus que demonstraram medo ao avistar os policiais. Enio estava com droga e dinheiro. Não se recorda se os réus disseram que a droga era para o próprio uso. Nenhum familiar dos réus chegou ao local. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos policiais, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente os réus ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu

Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuarão a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que os acusados transportavam as drogas apreendidas, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Agentes Públicos, que narraram verossimilmente, a apreensão das drogas, parte com o réu GEOVAN e outra parcela onde ÊNIO dispensou as drogas que transportava; 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 102/106), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas porções, própria da venda a varejo; 3) a não apreensão de qualquer instrumento ou apetrecho utilizado para o consumo das drogas; 4) a exata correspondência dos réus com os traficantes delatados anonimamente; 5) o comportamento suspeito do acusado ÊNIO, o qual, ao ver a aproximação da viatura, dispensou as drogas que trazia consigo; e 6) a confissão de ambos os réus em solo policial. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des.

Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "eppendorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da "cocaína" em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de "cocaína" provoca o "enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação" (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654; RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 102/106) e demonstrado que os réus incorreram em verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 - trazer consigo -, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que os réus perpetraram o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. I - DO RÉU ENIO. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as

circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual fixo sua pena no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que torno definitiva a mingua de outras causas modificadoras da pena a incidir. Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: "Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Ademais, deixei de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, eis que a figura do tráfico "privilegiado" exige a satisfação cumulativa de 04 requisitos, a saber primariedade, bons antecedentes, não pertencimento a organização criminosa e não dedicação a atividades delitivas. E o último requisito não foi preenchido in casu. Isso porque, a despeito da primariedade e bons antecedentes do acusado, tem-se revelado nas mensagens encontrados no celular do acusado (fls. 140 e ss.) que este se dedicava a traficância desde 09/06/2021, portanto demonstrada sua dedicação à atividades criminosas, muito antes dos atos, exclui-se a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. A propósito, assim também se posiciona a jurisprudência, entendendo que os elementos acima expostos são idôneos a indicar dedicação à atividades criminosas e afastar a figura do tráfico privilegiado: "6. A Corte Estadual, para manter o não reconhecimento do tráfico privilegiado, amparou-se na conclusão de que os Recorrentes agiram de forma organizada e, apesar de o fato de as drogas apreendidas serem bastante nocivas não justificar, por si só, a conclusão pela dedicação às atividades criminosas, foram utilizados outros elementos concretos para demonstrar a atuação dos Recorrentes em atividades criminosas, tais como: a quantidade de droga apreendida, a apreensão de balanças de precisão, as grandes quantidades de eppendorfs e saquinhos para confecção das porções, o valor de R\$ 1900,00 e o caderno de anotações da contabilidade dessa atividade. Portanto, é idônea a fundamentação utilizada para negar a minorante." (REsp n. 1.978.262/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.). Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, e, com fulcro no artigo 33, § 3º, c.c. art. 59, III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, que pelo caráter hediondo do crime, quer porque a prova dos autos indica que há meses se dedicava ao tráfico de entorpecentes. II - DO RÉU GEOVAN. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual fixo sua pena no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual fixo sua pena no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que torno definitiva a mingua de outras causas modificadoras da pena a incidir. Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública, pelas mesmas razões

acima expostas. Ademais, deixei de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, eis que a figura do tráfico "privilegiado" exige a satisfação cumulativa de 04 requisitos, a saber primariedade, bons antecedentes, não pertencimento a organização criminosa e não dedicação a atividades delitivas. E o último requisito não foi preenchido in casu. Isso porque, a despeito da primariedade e bons antecedentes do acusado, este fora preso em data posterior aos fatos, durante o gozo de liberdade provisória concedida em audiência de custódia, pela suposta prática do mesmo crime de tráfico (cf. fl. 219), o que demonstra sua persistência e dedicação nesta prática delitiva. A propósito, assim também se posiciona a jurisprudência, entendendo que os elementos acima expostos são idôneos a indicar dedicação à atividades criminosas e afastar a figura do tráfico privilegiado: "6. A Corte Estadual, para manter o não reconhecimento do tráfico privilegiado, amparou-se na conclusão de que os Recorrentes agiram de forma organizada e, apesar de o fato de as drogas apreendidas serem bastante nocivas não justificar, por si só, a conclusão pela dedicação às atividades criminosas, foram utilizados outros elementos concretos para demonstrar a atuação dos Recorrentes em atividades criminosas, tais como: a quantidade de droga apreendida, a apreensão de balanças de precisão, as grandes quantidades de eppendorfs e saquinhos para confecção das porções, o valor de R\$ 1900,00 e o caderno de anotações da contabilidade dessa atividade. Portanto, é idônea a fundamentação utilizada para negar a minorante." (REsp n. 1.978.262/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.). Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, e, com fulcro no artigo 33, § 3º, c.c. art. 59, III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, que pelo caráter hediondo do crime, quer porque o réu já recaia novamente na mesma prática delitiva, demonstrando que o regime inicial fechado é único capaz de conter eu ímpeto criminoso. III - DO DISPOSITIVO E DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para: 1) condenar os réus ENIO BASTOS DA SILVA e GEOVAN MARTINS DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incursos no artigo 33, caput da Lei 11343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal e 2) absolvê-los da imputação de infringência ao disposto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Defiro o Apelo em Liberdade, na medida em que, em relação ao réu Enio, permanecem inalteradas as razões que permitiram ao acusado responder a esse feito solto (fls. 49/53); já em relação ao réu Geovan embora tenha descumprido as condições de sua liberdade provisória, encontra-se preso por outro, sendo desnecessário determinar-se nova segregação cautelar. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão, guia de recolhimento, bem como arquivem-se os autos. Isento o acusado ENIO do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que foi assistido nos autos por defensora dativa (fls. 192). Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intime-se o réu ENIO para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. De outro lado, diante da parcial condenação, fica ainda obrigado o réu GEOVAN a recolher custas de 50 (cinquenta) UFESP's, na forma do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Não lhe concedi os benefícios da Justiça Gratuita, pois tal réu constitui advogada (fls. 98), signo presuntivo de riqueza que revela sua capacidade para suportar o ônus financeiro das custas processuais. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa e o montante referente às custas processuais. Após, intime-se o réu GEOVAN para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 390,00 em dinheiro - fls. 94) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminosa. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na

forma da lei. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP. Pelas Defensoras dos acusados foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM^a Juíza de Direito foi dito: "RECEBO os recursos interpostos pelos réus, saindo as Defensoras, desde já, intimadas a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente Certidão de Honorários à Patrona Dativa. Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe". Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Alisson Eduardo de Oliveira, Assistente Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA